Governo do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria Tributária

Manifestação.PGE/PG03/PTRIB SEI Nº28 Rio de Janeiro,03 de abril de 2023

PROCESSO Nº SEI-100006/001883/2022

Ref: CENTRAL. CONTRATO PRESI N°12/2021. BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO – BIRD.

CONSULTA REALIZADA QUESTIONANDO SE COMPETIRIA À CENTRAL PAGAR DIRETAMENTE AO FISCO OS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O CONTRATO.

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA E EVENTUAL SUJEIÇÃO PASSIVA DA COMPANHIA, PERANTE O FISCO, RELATIVAMENTE AO IRRF; CSLL; PIS/PASEP E COFINS; ISS; E CIDE-ROYALTIES.

Prezado Procurador Chefe

Trata-se de contrato de prestação de serviço e consultoria tendo como contratante a CENTRAL, empresa pública controlada pelo Estado, e contratada uma empresa estabelecida na Espanha denominada MCRIT.

O escopo do serviço era a elaboração de “Plano estratégico de adaptação às mudanças climáticas para os sistemas de transporte público de média e alta capacidade que atendem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro”.

Embora o contratante e o beneficiário do serviço seja a CENTRAL, a remuneração da contratada foi paga diretamente pelo Banco Mundial com recursos do próprio Banco Mundial.

Foram suscitadas basicamente duas questões relacionadas a pagamento dos tributos devidos sobre a prestação desse serviço.

A primeira questão está em saber se, pelo contrato celebrado entre as partes para disciplinar a prestação desse serviço, pagamento dos tributos de veria ser realizado pela CENTRAL ou pela contratada MCRIT.

Importante destacar que, pelo que foi possível compreender das manifestações anteriores, o ônus dos tributos devidos é da CENTRAL. Entretanto, o contrato apresenta uma ambiguidade entre as cláusulas 38.1 e 39.1 que tornaria possível uma interpretação no sentido de que a MCRIT deveria fazer o pagamento dos tributos devidos, embora a CENTRAL fosse obrigada a reembolsar a MCRIT pelo custo incorrido com o pagamento desses tributos.

> 38.1. O preço do Contrato é: R$ 933.500 e US$ 142.500 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos reais e cento e quarenta e dois mil e

> quinhentos dólares) excluído de impostos locais indiretos. Quaisquer impostos locais indiretos passíveis de cobrança em relação a este Contrato para os Serviços fornecidos pelo Consultor devem ser reembolsados pelo Cliente para o Consultor. O montante de tais impostos é R$ 22.485,00 e US$ 18.531,50.
>
> 39.1 e 39.2. O Cliente pagará em nome do Consultor, dos Subconsultores e dos Especialistas, quaisquer impostos indiretos, encargos, taxas, tributos e outras imposições aplicadas ao Consultor, aos Subconsultores e Especialistas nos termos da legislação aplicável no país do Cliente em relação a: (a) quaisquer pagamentos efetuados ao Consultor, Subconsultores e Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), juntamente com a realização dos Serviços; (b) quaisquer equipamentos, materiais e suprimentos trazidos para o país do Cliente pelo Consultor ou Subconsultores com o objetivo de realizar os Serviços e que, após terem sido trazidos para tais territórios, serão mais tarde retirados por eles; (c) quaisquer equipamentos importados, com o objetivo de realizar os Serviços e pagos com os recursos financeiros fornecidos pelo Cliente e que são tratados como bens do Cliente; (d) quaisquer bens trazidos para o país do Cliente pelo Consultor, quaisquer Subconsultores ou Especialistas (exceto nacionais ou residentes permanentes do país do Cliente), ou pelos dependentes legais daqueles Especialistas para seu uso pessoal e que serão posteriormente retirados por eles ao partirem do país do Cliente, desde que: (i) o Consultor, Subconsultores e Especialistas cumpram os procedimentos normais de alfândega do país do Cliente na importação de bens para o país do Cliente; e (ii) se o Consultor, Subconsultores ou Especialistas não retirarem, mas descartarem quaisquer bens no país do Cliente que tenham sido beneficiados com isenção de impostos e direitos aduaneiros, o Consultor, Subconsultores ou Especialistas, conforme o caso, (a) assumirão os impostos e direitos aduaneiros de acordo com as regulamentações do país do Cliente, ou (b) reembolsarão o Cliente caso este os tenha pagado no momento em que os bens em questão foram trazidos para o país do Cliente.

Essa interpretação está refletida no item 20 do PARECER Nº 10/2023/CENTRAL/ASSJUR/MJPM (46628498) do Procurador do Estado Mauricio Jorge Pereira da Mota:

> 20. Como se nota da leitura das Cláusulas acima transcritas, verifica-se que os itens 38.1 e 39.1/39.2 se encontram em contradição, uma vez que aquele estabelece que a obrigação de pagar os tributos incidentes sobre o contrato compete ao Consultor – cabendo ao Cliente, isto é, à CENTRAL, o mero reembolso -, enquanto estes afirmam que a obrigação de pagar os tributos diretamente ao Fisco cabe ao Cliente.

A segunda questão está em determinar quais tributos seriam devidos no caso em foco, considerando, em especial, a particularidade de o pagamento da MCRIT ter sido realizado no exterior, diretamente pelo Banco Mundial.

Essas questões foram muito bem analisadas e estão adequadamente resumidas no Parecer nº 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV da Assessoria Jurídica da CENTRAL, da lavra do Procurador do Estado Maurício Gomes Vieira, datado de 10/03/2023 (47724338), o qual conclui o seguinte:

> 13. Após a prolação do Parecer 10 (46628498), esta ASSJUR foi novamente questionada acerca da incidência de tributos sobre o Contrato PRESI N° 12/2021, tendo sido destacado pela DIRAF que “o setor

financeiro apurou (Lei 10.865 de 30/04/2004, dentre outras) também, a existência além dos impostos indiretos que não foram discriminados no referido contrato PRESI 012/2021, a ocorrência também das obrigações a pagar pelo contratante de serviços no exterior, no caso a CENTRAL, das contribuições Federais (PIS, COFINS, CSLL e CIDE)" (46783277).

14. Sobre o tema, cumpre destacar, preliminarmente, que todas as conclusões exaradas por esta ASSJUR no âmbito do Parecer 10 permanecem hígidas, entendendo esta Assessoria que, s.m.j., cumpre ao consórcio contratado o pagamento de todos os tributos incidentes sobre o Contrato ao Fisco, competindo à CENTRAL meramente o reembolso de tais valores.

15. Por outro lado, é certo que, ainda que plenamente válidas e eficazes perante as partes, as cláusulas contratuais não produzem efeitos perante o Fisco, nos termos do art. 123, do CTN, in verbis:

Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

16. Isso significa, pois, que, na hipótese de a legislação tributária prever que a responsabilidade pelo pagamento de determinados tributos, no caso concreto, competiria à CENTRAL, tal circunstância constituiria óbice à oposição das cláusulas do Contrato PRESI n° 12/2021 ao Fisco, sem prejuízo, porém, do eventual ajuizamento de ação de regresso em face do consórcio contratado, a quem compete, s.m.j., o pagamento dos tributos incidentes sobre o contrato.

84. Esta ASSJUR foi questionada, essencialmente, acerca da incidência de tributos e obrigação de sua retenção e pagamento pela CENTRAL no âmbito do Contrato PRESI N° 12/2021.

85. Sem prejuízo das conclusões exaradas no Parecer anterior proferido por esta ASSJUR, no qual se analisou a ausência de responsabilidade contratual da CENTRAL pela retenção e pagamento dos tributos, a presente manifestação passou a analisar o tema sob o prisma da incidência de tributos sobre o Contrato PRESI n° 012/2021 e eventual obrigação da Companhia de retenção e pagamento frente ao Fisco, tendo em vista a inoponibilidade dos contratos particulares à Fazenda, nos termos do art. 123, CTN.

86. Desse modo, analisou-se eventual incidência e sujeição passiva da CENTRAL frente ao Fisco no que tange aos seguintes tributos: IRRF; CSLL; PIS/PASEP e COFINS; ISS; e CIDE-royalties. Chegou-se, ao final, às seguintes conclusões:

(i) No que tange ao IRRF, tendo em vista as informações disponíveis nos autos, entende esta ASSJUR que, s.m.j., não pode ser a CENTRAL considerada como responsável pela retenção na fonte e transferência à União de imposto de renda no caso em tela, considerando que os pagamentos, no âmbito do Contrato PRESI n° 12/2021, são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 744 do Decreto n° 9.580/2018;

(ii) No que se refere à CSLL, pôde-se concluir que, s.m.j., nos termos da legislação aplicável ao tributo, o Consultor contratado domiciliado no exterior não pode ser considerado contribuinte de tal tributo, afastando-se, pois, sua incidência do caso em tela. Não obstante, ainda que houvesse falar em incidência da CSLL, não poderia a CENTRAL ser considerada responsável pela retenção na fonte e transferência da Contribuição à União, considerando que os pagamentos são realizados ao Consultor contratado diretamente pelo Banco Mundial, de modo que não se enquadra a Companhia no disposto no art. 1°, IN SRF 459/04;

(iii) No que concerne a PIS/PASEP e COFINS, nos termos da legislação que rege a matéria, ainda que não seja a CENTRAL a entidade que, faticamente, enseja a ocorrência do fato gerador dos tributos em análise – tendo em vista que, conforme informado pela SUPFIC, os pagamentos ao prestador de serviços domiciliado no exterior são realizados diretamente pelo Banco Mundial -, considerando ser a Companhia a contratante e beneficiária dos serviços prestados, parece ser possível concluir que, s.m.j., deve ser a CENTRAL considerada sujeito passivo da obrigação tributária de pagamento de PIS/PASEP e COFINS à União;

(iv) Quanto ao ISS, em análise da Lista Anexa da LC n° 116/03, esta ASSJUR concluiu que, ao que parece, os serviços prestados pelo Consultor contratado enquadram se no disposto no item 2.01 ou, possivelmente, no item 7.03. Cumpre destacar, porém, que a análise acerca do enquadramento, ou não, dos serviços prestados pelo Consultor contratado a uma das hipóteses previstas na Lista Anexa da LC n° 116/03 é eminentemente técnica, não possuindo esta ASSJUR a expertise necessária para proferir parecer definitivo sobre o tema. Dessa maneira, cumpre aos setores técnicos da CENTRAL efetuar tal exame. Ultrapassada essa questão, e supondo, a título provisório, haver efetivamente a incidência de ISS ao caso em tela, tendo em vista caracterizar-se a CENTRAL como tomadora dos serviços contratados, nos termos da legislação municipal que rege a matéria, deve se considerar a Companhia como sujeito passivo do ISS perante o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de responsável tributária;

(v) Por fim, no que concerne à CIDE-royalties, parece a esta ASSJUR que, s.m.j., os serviços contratados enquadram-se no conceito legal de “serviços técnicos”, a fazer incidir a CIDE-royalties ora analisada, nos termos do entendimento da Receita Federal sobre o tema. Ultrapassada essa questão, parece ser possível concluir que pode a CENTRAL ser considerada sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 2°, §§2° e 6°, da Lei n° 10.168/2000.

87. Sugere-se, outrossim, seja efetuada consulta à Secretaria da Receita Federal acerca de eventual incidência e obrigação de pagamento pela CENTRAL no que concerne aos tributos analisados de competência da União, a fim de confirmar o entendimento do Fisco sobre a matéria e orientar eventual decisão dos gestores da Companhia.

88. Sem prejuízo das conclusões acima exaradas, tendo em vista a repercussão geral e complexidade da matéria - uma vez que se trata de contrato que envolve transferência de recursos do Banco Mundial, que pode impactar em diversos contratos da Administração Pública bem como por se tratar de matéria específica de direito tributário, sobre a qual esta ASSJUR não possui atribuição para a prolação de parecer definitivo -,

remete-se o feito à d. PGE, nos termos do art. 4°, V, 'h', do Decreto n° 40.500/07.

Feita essa breve introdução passamos ao nosso parecer.

Invertendo a ordem das questões, podemos antecipar a nossa opinião no sentido de que nos parece correto o entendimento exposto pelo Procurado do Estado Mauricio Gomes Vieira no que diz respeito aos tributos devidos.

De fato, razoável interpretar art. 744 do Decreto n° 9.580/2018 no sentido de que o IR somente seria devido caso estivesse havendo o pagamento por uma fonte situada no País, o que não está ocorrendo. Da mesma forma razoável interpretar somente é contribuinte da CSLL a pessoa jurídica estabelecida no Brasil, o que afasta a incidência desse tributo neste caso.

No que diz respeito aos demais tributos que incidem sobre a importação de serviços (PIS/COFINS, ISS e CIDE) nos parece razoável a interpretação da legislação tributária no sentido de ser irrelevante o fato de não estar havendo remessa ao exterior por fonte pagadora residente no Brasil. Ou seja, o fato de o pagamento estar sendo realizado diretamente no exterior pelo Banco Mundial não afasta o fato gerado desses tributos e, consequentemente, a responsabilidade da CENTRAL pelo pagamento deles na condição de beneficiária dos serviços prestados.

Outro tributo que poderia ser mencionado e geralmente incide na importação de serviços é o IOF que incide na contratação da compra de moeda estrangeira para fazer o pagamento (fechamento de contrato de câmbio). Mas como não houve fechamento de câmbio, também não há do que se cogitar da incidência desse tributo aqui.

Entretanto, no que diz respeito à discussão sobre se a obrigação de efetuar o pagamento dos tributos devidos seria da CENTRAL ou da MCRIT gostaríamos de fazer uma ligeira observação, que ao nosso modo de ver não altera substancialmente a orientação do parecer do Procurado Maurício Gomes Vieira.

Salvo algum entendimento equivocado do nosso lado, aparentemente existe pouca relevância prática discutir se a obrigação de pagar os tributos devidos é da CENTRAL ou da MCRIT.

Na realidade, caso a CENTRAL tenha que realizar uma remessa para a MCRIT para cobrir o custo do pagamento dos tributos eventualmente efetuado por ela, possível que o valor dos tributos devidos acabe até sendo aumentado porque nesse caso os tributos poderão ser considerados incluídos dentro da remuneração devida à MCRIT. É o que se chama de "cálculo por dentro", no qual o tributo deve ser calculado considerando que ele está incluído na sua própria base de cálculo (tal como ocorre com o ICMS).

Além disso, em que pese a ambiguidade do contrato, a bem da verdade comum que uma empresa estrangeira não assuma a obrigação de calcular e efetuar o pagamento dos tributos devidos no Brasil. Até pela completa ausência de estrutura administrativa e contábil no Brasil, seria muito difícil para uma empresa estrangeira cumprir essa obrigação.

Essa questão poderia ter mais relevância se o que estivesse sendo discutido fosse a responsabilidade pelo pagamento de encargos moratórios. Nesse caso, demonstrada que o atraso no pagamento dos tributos seria de responsabilidade da MCRIT, então seria razoável que ela assumisse o custo correspondente aos encargos moratórios. Entretanto, esse não parece ser a hipótese aqui.

Seja como for, voltando à questão dos tributos devidos neste caso, o Procurador do Estado Maurício Vieira está sugerindo a formulação de consulta tributária à Secretaria da Receita Federa (item 87 do I, Parecer nº 14/2023/CENTRAL/ASSJUR/MGV) o que consideramos prudente diante

das particularidades deste caso.

Em face do exposto, sem prejuízo da possibilidade de ser efetuada a consulta tributária referida acima, o nosso parecer é no sentido de que o pagamento dos tributos devidos, conforme entendimento do Procurador Maurício Gomes de Souza, seja efetuado pela CENTRAL, não se exigindo que a MCRIT faça esse pagamento para somente depois ser efetuado o seu reembolso pela CENTRAL.

Sem mais, para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

José Roberto P. C. Faveret Cavalcanti
Procurador do Estado
Procuradoria Tributária



Documento assinado eletronicamente por **Jose Roberto Penna Chaves Faveret Cavalcanti**, **Procurador**, em 03/04/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019 .



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **49723678** e o código CRC **C71E9815**.

Referência: Processo nº SEI-100006/001883/2022 SEI nº 49723678

R. do Carmo, 27, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-020
Telefone: (21) 2332-7397 - https://www.pge.rj.gov.br/